

刑法
No24

共通問題 R1-1

(配点：2)

月 日

月 日

不作為犯に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 不作為犯は、結果発生を防止しなければならない義務が法律上の規定に基づくものでない場合であっても、成立する余地がある。

イ. 不作為犯は、死体遺棄罪についても成立する余地がある。

ウ. 不真正不作為犯の故意は、結果の発生を意欲していなくても、認められる余地がある。

エ. 不作為犯は、作為可能性がない場合であっても、成立する余地がある。

オ. 不作為犯の因果関係は、期待された作為に出ているれば結果が発生しなかったことが、合理的な疑いを超える程度に確実であったといえない場合であっても、その可能性さえあれば、認められる余地がある。

1. ア イ 2. ア ウ 3. イ エ 4. ウ オ 5. エ オ

No24	不作為犯	正答率
共通R 1-1	正 解	90%
	5	

ア 正しい

最決平 17.7.4 (百選 I 6 事件) は、重篤な患者の親族から患者に対するシャクティ治療を依頼された被告人に、「直ちに患者の生命を維持するために必要な医療措置を受けさせる義務」があったとしている。その理由として、判例は、「被告人は、自己の責めに帰すべき事由により患者の生命に具体的な危険を生じさせた上、患者が運び込まれたホテルにおいて、被告人を信奉する患者の親族から、重篤な患者に対する手当てを全面的にゆだねられた立場にあった」ということを挙げている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、法令、契約、先行行為、排他的支配及び保護の引受けは、それぞれが作為義務の根拠となりうるが、そのうちのどれか 1 つだけで作為義務が肯定または否定される場合のすべてを説明するのは困難であり、現時点では、これらの根拠を総合的に考慮し、問題となる不作為を作為の実行行為と同視できるかという観点から作為義務の有無を判断するほかないということを挙げている。

イ 正しい

大判大 6.11.24 は、母親が新生児を砂中に埋めて窒息死させ、死体をそのまま放置した事案において、死体遺棄罪の成立を認めている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、死体遺棄罪における「遺棄」については、刑法 217 条及び 218 条の遺棄罪とは法益が異なり、また、不保護の規定がないことから、不作為も含まれるということを挙げている。

ウ 正しい

最決平 17.7.4 (百選 I 6 事件) は、重篤な患者の親族からシャクティ治療を依頼された被告人が入院中の患者を病院から運び出し、未必的な殺意をもって、患者の生命を維持するために必要な医療措置を受けさせないまま放置し死亡させた事案で、不作為による殺人罪の成立を認めている。

エ 誤っている

不作為による実行行為が肯定されるためには、作為義務のほか、作為可能性・容易性が認められることが必要である。学説は、その理由として、作為可能性がないものに作為を要求することは無意味であり、不当であるということを挙げている。

オ 誤っている

最決平元 12.15 (百選 I 4 事件) は、被告人が救命医療を要請しなかった不作為と被害者の死亡結果との間に因果関係が認められるか問題となった事案において、「被害者の女性が被告人らによって注射された覚せい剤により錯乱状態に陥った午前零時半ころの時点において、直ちに被告人が救急医療を要請していれば、同女が年若く (当時 13 年)、生命力が旺盛で、特段の疾病がなかったことなどから、十中八九同女の救命が可能であったというのである。そうすると、同女の救命は合理的な疑いを超える程度に確実であったと認められるから、被告人がこのような措置をとることなく漫然同女をホテル客室に放置した行為と午前 2 時 15 分ころから午前 4 時ころまでの間に同女が同室で覚せい剤による急性心不全のため死亡した結果との間には、刑法上の因果関係がある」としている。学説でも、一般に、結果回避の確実性が認められる場合、すなわち結果回避が合理的な疑いを超える程度に確実であったと認められる場合に因果関係を肯定できるとされている。

以上により、誤っている記述はエとオであり、したがって、正解は肢 5 となる。